

1506383-93.2020.8.26.0526

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 17/03/2022

... 24/6/2021, publicado no PJe: 1/7/2021).

TRÁFICO DE DROGAS - pretensão de aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º da lei de drogas, e a fixação de regime inicial aberto - inviável - dosimetria - reincidência afastada, menoridade relativa valorada - inadmissível o reconhecimento do tráfico privilegiado - agente contumaz na prática do tráfico de drogas, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

3ª Vara

Av. Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1506383-93.2020.8.26.0526 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506383-93.2020.8.26.0526

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2315040/2020 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 15270804 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2291/20/610 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2315040 - DEL.POL.SALTO, 2291/20/610 - DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL ALVES DA SILVEIRA FERREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público contra o réu GABRIEL ALVES DA SILVEIRA FERREIRA, por infração no art. 33, "caput" da Lei Federal nº 11.343/06, porque, em tese, no dia 17 de dezembro de 2020, por volta das 22h23min, na Rua Vaticano, nº 416, Jardim União, nesta cidade e comarca de Salto/SP, o acusado, em ocasião de calamidade pública, guardava e trazia consigo, para entrega a consumo e fornecimento, ainda que gratuito, 17 (dezessete) porções de "cocaína", com peso líquido de 6,8g (seis gramas e oito decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi oferecida em 19 de maio de 2021 (fls. 61-64).

O réu foi notificado pessoalmente e apresentou defesa escrita (fls. 71).

A denúncia foi recebida em 26 de agosto de 2021 (fls. 88-89) e o réu citado.

Durante a instrução processual o réu foi interrogado e foram inquiridas duas testemunhas arroladas pela acusação.

Nas alegações finais orais o Ministério Público requereu a condenação do réu nos

termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, requereu o reconhecimento da inimputabilidade do réu, a absolvição ou a desclassificação do crime, ou ainda alternativamente, a aplicação da pena no mínimo legal e substituição por pena restritiva de direito.

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

A ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fl.01), boletim de ocorrência (fls.02-04), auto de exibição e apreensão (fl.05.), auto de constatação preliminar (fl.07) e laudo de exame químico toxicológico (fls.55-57) bem como por toda prova oral coligida nos autos.

A autoria do crime de tráfico também é certa.

A testemunha Marcos Roberto Carlos, guarda civil municipal, disse que estavam em patrulhamento, na Rua Vaticano avistaram Gabriel segurando um saco plástico azul e entregando algo a uma pessoa que não foi identificada. Ao notar a aproximação da viatura, o rapaz correu e Gabriel escondeu algo na cueca. Feita a revista pessoal, localizou-se 1 (um) microtubo de cocaína que ele havia escondido na cueca e 16 (dezesesseis) microtubos de cocaína no interior da mencionada sacola, além de R\$ 165,00 em dinheiro. Questionado, ele confessou que estava vendendo drogas naquele local desde às 19h00, pois passava por dificuldades financeiras.

O réu não compareceu, sendo revel, vide certidões em fls. 81 e 132.

O guarda municipal ouvido em Juízo apresentou versão firme, coerente e rica em detalhes demonstrando que avistaram o réu com uma sacola na mão e entregando algo a um terceiro que fugiu. Com Gabriel encontraram 1 (um) microtubo de cocaína escondido na cueca e 16 (dezesesseis) microtubos de cocaína no interior da sacola que ele levava.

As declarações de policiais e guardas municipais possuem relevância e autorizam a condenação, quando isentos de má-fé ou suspeição, e apoiados nos demais elementos de prova, como na hipótese. Além disso, cuida-se de crime permanente e guardas municipais podem realizar prisão em flagrante. Finalmente, não há qualquer indício de prova que autorize concluir que os guardas tenham mentido para prejudicar o réu. Nesse sentido tem-se a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

Tráfico ilícito de entorpecentes. Preliminares afastadas. Ilicitude de provas por terem sido obtidas por guardas civis municipais não constatada. Inteligência do artigo 144, § 8º, da CF, regulamentado pela Lei 13.022/2014, em interpretação conjunta com o artigo 301, do Código de Processo Penal. Preliminar de nulidade por violação de domicílio. Não ocorrência. Existência de fundada suspeita apta a justificar o ingresso no imóvel. Réu flagrado ao sair de ponto conhecido de comércio espúrio, sendo abordado e apreendido em seu poder a quantia injustificada de R\$ 40,00. Em incursão por viela próxima ao local, os agentes estatais, após iluminarem o imóvel que estava com a porta aberta, avistaram uma sacola preta, contendo, em seu interior, 65 porções de cocaína, com massa líquida de 26,62 gramas, e 90 porções de maconha, com peso líquido de 220,67 gramas. Cômodo pertencente ao acusado. Violação não constatada. Entendimento pacificado pelo STF em repercussão geral (tema 280). Pleito absolutório Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos guardas municipais. Negativa do réu isolada. Tráfico evidenciado. Condenação mantida.

Reforma das penas. Bases indevidamente fixadas acima dos mínimos legais, por ocasião da quantidade de droga. Volume que não justifica maior reprovabilidade da conduta. Acusado primário e possuidor de bons antecedentes. Exclusão da agravante da calamidade pública. Aplicação do redutor à fração máxima. Penas finalizadas em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa. Regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade. Parcial provimento ao apelo. (TJSP; Apelação Criminal 1503301-54.2020.8.26.0526; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Salto - 2ª Vara; Data do Julgamento: 14/12/2021; Data de Registro: 14/12/2021)

TRÁFICO ILÍCITO E ASSOCIAÇÃO. Recursos defensivos. PRELIMINARES. Pedido de liberdade provisória. Prejudicado pelo julgamento Colegiado. Suposta prova lícita. Desnecessidade de mandado em se tratando de crime permanente. Prisão por Guarda

Municipal. Possibilidade. Inteligência da Lei nº 13.022/14 (Estatuto das Guardas Civis). Rejeição. ART. 33, CAPUT. Absolvição Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. ART. 35, CAPUT. Reversão da condenação. Viabilidade. Não demonstração de estabilidade e caráter duradouro. Mero concurso de agentes. DOSIMETRIA. Redução do aumento na primeira etapa de DOUGLAS. Afastamento da reincidência (trânsito em julgado afastado pelo HC nº 2290149-29.2020.8.26.0000, j. 19/3/2021, 8ª Câmara, TJSP). Manutenção da agravante da calamidade. Reconhecimento da menoridade relativa de DENILSON. Penas de DOUGLAS e DENILSON reduzidas.

Inaplicabilidade da benesse do art. 33, § 4º. Regime fechado preservado. ISENÇÃO DAS CUSTAS. Inviabilidade. Inteligência da Lei nº 1.060/50 e Lei Estadual nº 11.608/03. PROVIMENTO PARCIAL. (TJSP; Apelação Criminal 1501786-81.2020.8.26.0526; Relator (a): Eduardo Abdalla; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Salto - 1ª Vara; Data do Julgamento: 07/10/2021; Data de Registro: 08/10/2021). Em que pese a negativa de autoria pelo acusado, certo é que os demais depoimentos colhidos em conjunto com as provas materiais produzidas, são suficientes a embasar o decreto condenatório, haja vista que o acusado foi preso em flagrante após os guardas municipais o presenciarem de posse de uma sacola praticando ato de mercancia consistente em entrega da droga a um indivíduo não identificado, não sendo crível que tais pessoas mentissem apenas para prejudicar o réu.

O simples fato de a Defesa alegar que o réu é usuário não afasta a conclusão de que ele praticava a traficância, não é incomum que o traficante seja também usuário. Além disso, não restou minimamente demonstrado que o réu fosse inimputável no momento do crime. A respeito do ônus da prova por parte do acusado, esclarece Guilherme de Souza Nucci in Provas no Processo Penal (2015; p.35):

"Ao réu, se pretende apenas negar a imputação, resta permanecer inerte, pois nenhum ônus lhe cabe. Seu estado de inocência prevalece. Entretanto, se a estratégia de defesa tiver por meta alegar fato diferenciado daqueles constantes da denúncia ou queixa, chama a si o ônus da prova. É o que, naturalmente, ocorre com a sustentação do alibi (dizer que estava em local diverso daquele onde aconteceu o crime). Buscará o acusado, por interesse seu, demonstrar ao juiz a autenticidade de sua informação. Cabe-lhe o encargo, a responsabilidade. Não demonstrado o alibi, permanece o réu na sua condição de inocente, mas, provavelmente, a acusação conseguirá avançar, ainda mais, na sua linha de demonstração de que ele é culpado."

No que se refere à agravante do art. 61, inciso II, alínea "j", inexistem elementos que indicam que o réu tivesse se aproveitado da situação de calamidade pública para praticar o delito. Com efeito, o estado de emergência sanitária não facilitou a execução da conduta delituosa. Não houve, portanto, aproveitamento, pelo réu, daquela situação o que, na hipótese positiva, poderia sim conferir uma maior reprovabilidade à ação. Conforme julgou o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Defesa pretende a redução da pena, afastamento da agravante do delito praticado durante a pandemia do COVID-19, compensação das atenuantes com a recidiva e o abrandamento do regime prisional. Parcial acolhimento. Autoria e materialidade sobejamente comprovadas sequer foram objeto do recurso defensivo. Prisão em flagrante. Réu confesso. Seguro relato das testemunhas descrevendo a dinâmica criminoso e imputando ao acusado a responsabilidade pelos fatos narrados na denúncia. Condenação inevitável.

Dosimetria comporta reparos. Na segunda etapa, necessário afastar a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Da mesma forma, imperioso compensar as atenuantes da confissão e da menoridade relativa com a agravante da reincidência. Súmula 545 do E. STJ. Impossível a concessão do privilégio. Regime fechado decorre de expressa determinação legal e foram devidamente fundamentados nos autos. Súmulas nº 718 e 719 do C. STF e 440 do e. STJ. Inviável a substituição por restritiva de direitos. Recurso parcialmente provido" (TJSP: Apelação Criminal 1512067-20.2020.8.26.0228; Relator (a): ANDRADE SAMPAIO; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Barra Funda, 32ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/02/2021; Data de Registro: 13/02/2021).

De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, nos crimes de tráfico ilícito

de entorpecentes, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

No presente caso, apesar da primariedade, conforme se observa na certidão de objeto e pé fls. 103, o réu foi preso em flagrante delito pela prática de tráfico de drogas em 15 de janeiro de 2021, ou seja, pouco mais de um mês após ser concedida a liberdade provisória nestes autos, evidenciando, assim, seu engajamento no comércio clandestino de drogas, circunstância impeditiva da aplicação do privilégio, uma vez que não preenchidos todos os requisitos do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

O intuito do legislador em estabelecer o tráfico privilegiado é de beneficiar um agente que, por algum desvio pontual de percurso, ingressar pela primeira vez no cometimento de crime. Tanto é que o agente deve preencher todos os requisitos do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006 e não somente a primariedade. Nesse sentido tem-se a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS DESTINADO AO PRÓPRIO CONSUMO. INVIABILIDADE. SITUAÇÃO DE TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inviável a absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 quando, do conjunto probatório, constata-se que o apelante trazia consigo, porções de drogas para fins de difusão ilícita. 2. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroboradas por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 3. Ainda que não seja expressiva a quantidade de maconha apreendida com o acusado (31,32g - trinta e uma gramas e trinta e duas centigramas), seu acondicionamento em porções menores, envoltas em trouxas de plástico independentes, indica sua destinação à traficância ilícita. Outrossim, com o acusado foi encontrado considerável montante em dinheiro fracionado, o que evidencia a proveniência do tráfico de drogas. 4. Os inquéritos e ações penais em curso podem afastar a figura do tráfico privilegiado quando evidenciarem a dedicação do agente às atividades criminosas, de modo a impedir o preenchimento dos requisitos cumulativos trazidos pelo art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, para o reconhecimento de tal causa de diminuição de pena. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1350057, 07142757420198070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no PJe: 1/7/2021).

TRÁFICO DE DROGAS - pretensão de aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º da lei de drogas, e a fixação de regime inicial aberto - inviável - dosimetria - reincidência afastada, menoridade relativa valorada - inadmissível o reconhecimento do tráfico privilegiado - agente contumaz na prática do tráfico de drogas, PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES ESPECÍFICOS, QUE REVELAM dedicação AO TRÁFICO de maneira HABITUAL - regime inicial fechado adequadamente estabelecido - penas redimensionadas - recurso parcialmente provido. (TJ-SP - APR: 00030078820188260286 SP 0003007-88.2018.8.26.0286, Relator: Amaro Thomé, Data de Julgamento: 05/06/2020, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 05/06/2020)

Assim, satisfatoriamente comprovadas a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, passo a dosagem das penas.

Analisada as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o réu é primário, culpabilidade, conduta social, personalidade do agente, motivos são normais à espécie, as circunstâncias e consequências do crime, não podem ser valorados negativamente, razão pela qual fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, ausente agravante do art. 61, inciso II, alínea "j" e presente a atenuante da menoridade, porém, mantenho a pena no mínimo legal, conforme súmula 231 do STJ.

Ausentes causa de diminuição e aumento, torno definitiva a pena de 5 anos de

reclusão e 500 dias-multa, no mínimo legal.

Diante da quantidade de pena aplicada e sendo o réu tecnicamente primário, o regime é o semiaberto (artigo 33, §2º, alínea 'b' e §3º, do Código Penal).

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e incompatível com o benefício da suspensão da pena, uma vez que não preenchidos os requisitos do artigo 44 e do 77 a 82, todos do CP.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR o réu GABRIEL ALVES DA SILVEIRA FERREIRA, qualificada nos autos, ao cumprimento da pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal, por incurso no artigo 33, caput, da Lei de Tóxicos.

O réu respondeu ao processo solto e, por isso, poderá apelar em liberdade, se por outro processo não estiver preso.

Publique-se e intime(m)-se.

Salto, 17 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA